

1013173-65.2022.8.26.0564

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Indenização por Dano Moral

Magistrado: Rodrigo Faccio da Silveira

Comarca: São Bernardo do Campo

Foro: Foro de São Bernardo do Campo

Vara: 3ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 09/12/2022

... que, imediatamente após o roubo a demandante procedeu a comunicação com as instituições bancárias nas quais possuía depósitos, bem como tentou acessar o sistema iCloud através da plataforma online disponibilizada pela demandada, em vão; que, com o aparelho em mãos o meliante efetuou e/ou tentou efetuar um sem número de delitos dentre eles (I) furto de valores depositados em conta ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

3ª Vara Cível

Rua Vinte e Três de Maio, 107 - Vila Tereza

CEP: 09606-000 - São Bernardo do Campo - SP

Telefone: (11) 2845-9605 - E-mail: saobernardo3cv@tjsp.jus.br

SENTENÇA

Processo n.º:

1013173-65.2022.8.26.0564

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Moral

Demandante:

BARBARA FERREIRA DE ALMEIDA

Demandado:

APPLE COMPUTER BRASIL LTDA.

1. Pág./págs. 1-5.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c.c. pedido de indenização movida por BARBARA FERREIRA DE ALMEIDA contra APPLE COMPUTER BRASIL LTDA.

Narra a inicial que a demandante contratou da demandada, mediante pagamento de mensalidade, os serviços por ela prestados de armazenamento de arquivos em 'nuvem' através de seu sistema iCloud, com acesso por meio do celular e/ou plataforma online disponibilizada pela demandada; que, o serviço era pago; que, a demandante foi roubada, tendo seu celular subtraído; que, imediatamente após o roubo a demandante procedeu a comunicação com as instituições bancárias nas quais possuía depósitos, bem como tentou acessar o sistema iCloud através da plataforma online disponibilizada pela demandada, em vão; que, com o aparelho em mãos o meliante efetuou e/ou tentou efetuar um sem número de delitos dentre eles (I) furto de valores depositados em conta bancária da demandante, (II) realização de compras utilizando seus cartões de crédito, PIX, bem como (III) acessou e violou o citado sistema de 'nuvem' acessando os dados lá armazenados, e alterando inclusive a senha de acesso de modo a impedir o acesso; que, a demandada nada fez para restaurar os dados; que, houve falha na prestação de serviços da demandada. Pede: I) a condenação da demandada à obrigação de restaurar os arquivos relacionados à conta Barbara.bfa@icloud.com, anteriores a 18/3/2022, possibilitando o acesso da demandante à conta/nuvem; II) a condenação da demandada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R\$ 20.000,00. Subsidiariamente, caso haja impossibilidade material de recuperação dos arquivos, requer a conversão da prestação de fazer em perdas e danos, cujo valor indenizatório deverá se dar por

meio de liquidação.

Juntou documentos às pág./págs. 12-32.

Citada (pág. 46), a demandada APPLE COMPUTER BRASIL LTDA apresentou contestação às pág./págs. 47-66, alegando a segurança nos serviços prestados; que é praticamente impossível que um terceiro saiba a senha sem que o usuário a tenha fornecido; que, a demandante confessa que o celular foi subtraído juntamente com a senha de acesso à sua conta iCloud; que, a demandante não comprova que, mesmo após a subtração do seu aparelho celular juntamente com a senha, tenha acionado o sistema "MODO PERDIDO" ou realizado o apagamento remoto para excluir todos os dados armazenados no aparelho, como recomendado no site da Ré em caso de perda, roubo ou furto de aparelho, impedindo, assim, que terceiros tivessem acesso aos dados armazenados no aparelho e/ou viessem a utilizá-lo; que, verificou-se que não foi possível à demandante a recuperação da conta até o momento, pois as informações por ela fornecidas não se assemelham àquelas cadastradas por ela no momento da criação da conta, além disso, consta que ela não tem acesso ao número de confiança por ela mesmo cadastrado, não fazendo jus, portanto, a alegação de que a demandada dificulta o acesso à conta ou, ainda, que estaria limitando seu direito de acesso aos dados. Pede a improcedência dos pedidos da demandante.

Réplica às pág./págs. 91-94.

Instados a especificarem as provas que pretendiam produzir (pág. 95), ambas as partes requereram o julgamento antecipado da lide (pág./págs. 98 e 99).

Eis o relatório.

2. FUNDAMENTAÇÃO.

Sob o fundamento do art. 355, I, do Código de Processo Civil, passa-se ao julgamento do feito no estado em que se encontra.

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização, em que a demandante, usuária dos serviços prestados pela demandada, pretende compelir esta à restaurar os arquivos relacionados à conta Barbara.bfa@icloud.com, anteriores ao roubo de seu aparelho celular. Alega que o serviço era pago e diante da falha na prestação de serviços busca também a reparação por danos morais.

Pois bem.

De início, evidente a relação de consumo na espécie, figurando a demandante como consumidora e a demandada como fornecedora (CDC, art. 2º e 3º).

Incidente, pois, as disposições do Código de Defesa do Consumidor.

No entanto, in casu, não se verifica a possibilidade de condenação da demandada.

Isso porque, ainda que a demandante pague pelos serviços da demandada, cumpre a ela, usuária dos serviços, realizar o backup dos dados e arquivos que deseja a transferência para 'nuvem'.

E, quanto a isso, não há provas nos autos de que a demandante tenha realizado qualquer backup.

Não fora isso, como esclarecido pela demandada em contestação:

"Ocorre que, em consulta aos seus registros, a Ré verificou que não foi possível à Autora a recuperação da conta até o momento, pois as informações por ela fornecidas não se assemelham àquelas cadastradas por ela no momento da criação da conta, além disso, consta que ela não tem acesso ao número de confiança por ela mesmo cadastrado, não fazendo jus, portanto, a alegação de que a Ré dificulta o acesso à conta ou, ainda, que estaria limitando seu direito de acesso aos dados.

Assim, quando a Autora requereu o restabelecimento da conta, a Ré verificou que os dados fornecidos por ela não correspondiam exatamente com os dados constantes no sistema (até porque se estes estivessem absolutamente corretos o desbloqueio poderia ter sido realizado via sistema, sem qualquer interferência dos prepostos da Ré) e, diante deste cenário, a Ré se viu impedida por suas regras de compliance, política de segurança e privacidade e, principalmente, em obediência à Lei 12.737/2012, de realizar qualquer procedimento.(pág. 61)

...

.. a Apple não tem acesso e não realiza backups (cópia de segurança) dos dados dos seus usuários, por uma questão de segurança e privacidade e, especialmente, em respeito à política de segurança e privacidade bem como em respeito à Lei 12.737/2012 (mais conhecida como Lei Carolina Dieckmann).” (pág. 62)

E, a despeito de a demandante não ter juntado aos autos provas de que realizou o backup dos arquivos que pretende a restauração, observa-se que a demandada ficou impossibilitada de fornecer ajuda à demandante, diante mesmo da divergência de dados desta no sistema, fato assumido pela demandante na inicial, confira-se item 8 e pág. 3:

Imediatamente após o roubo a Requerente procedeu a comunicação com as instituições bancárias nas quais possuía depósitos, bem como tentou acessar o sistema iCloud através da plataforma online disponibilizada pela Requerida. Em vão. Com o aparelho em mãos o

meliante de maneira audaz e velocíssima efetuou e/ou tentou efetuar um sem número de delitos dentre eles (I) furto de valores depositados em conta bancária da Requerente, (II) realização de compras utilizando seus cartões de crédito, PIX, bem como (III) acessou e violou o citado sistema de ‘nuvem’ acessando os dados lá armazenados, e alterando inclusive a senha de acesso de modo a impedir que a própria Requerente acessasse-o.

Ora, se o “meliante” alterou a senha e a forma de acesso aos dados da demandante, fica impossível compelir a demandada à obrigação de restaurar os dados desta, tendo em vista que as informações fornecidas não coadunam com os dados constantes do sistema da demandada.

O boletim de ocorrências juntado às pág./págs. 18-20 demonstra de forma clara que:

Detalhe da Ocorrência

ALÉM DA BOLSA E DAS JOIAS FOI LEVADO MEU APARELHO CELULAR IPHONE XS JUNTAMENTE COM A SENHA DO APARELHO QUE TINHA MEU ACESSO DO ICLOUD, FOI ALTERADO O NÚM. DE REGISTRO E EU AINDA NÃO CONSEGUI RECUPERAR O REGISTRO COM A APPLE ATÉ O MOMENTO E ESTÃO UTILIZANDO MEUS DADOS DO IPHONE PARA COMPRAS ONLINE (Destacamos).

Assim, o aparelho celular da demandante fora dela subtraído com a senha do aparelho que tinha acesso ao ICLOUD.

Entende-se, pois, que a demandante não agiu com a diligência que se lhe exigia. Isso porque, ao manter sua senha pessoal junto ao aparelho, possibilitou que terceira pessoa o utilizasse e tivesse acesso aos seus dados.

Enfim, a própria demandante permitiu que o sistema de segurança implantado pelo demandado fosse burlado.

Nesse sentido, “mutatis mutandis” a jurisprudência:

“RECURSO ESPECIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MATERIAIS - SAQUES INDEVIDOS EM CONTA-CORRENTE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - ART. 14, § 3º DO CDC - IMPROCEDÊNCIA.

1 - Conforme precedentes desta Corte, em relação ao uso do serviço de conta-corrente fornecido pelas instituições bancárias, cabe ao correntista cuidar pessoalmente da guarda de seu cartão magnético e sigilo de sua senha pessoal no momento em que deles faz uso. Não pode ceder o cartão a quem quer que seja, muito menos fornecer sua senha a terceiros. Ao agir dessa forma, passa a assumir os riscos de sua conduta, que contribui, à toda evidência, para que seja vítima de fraudadores e estelionatários. (RESP 602680/BA, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, DJU de 16.11.2004; RESP 417835/AL, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO JÚNIOR, DJU de 19.08.2002).

2 - Fica excluída a responsabilidade da instituição financeira nos casos em que o fornecedor de serviços comprovar que o defeito inexistiu ou que, apesar de existir,

a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º do CDC).
3 - Recurso conhecido e provido para restabelecer a r. Sentença" (STJ - REsp 601.805-SP, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, j. 20/10/2005)

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, assim dispõe:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

§ 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Portanto, a responsabilização do fornecedor de serviços, bem como a obrigação de indenizar surge apenas quando estão presentes todos os elementos acima mencionados no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, e ausentes as excludentes de responsabilidade.

In casu, tem-se como incontroversos os fatos de: I) a demandante ser cliente da demandada; II) a demandante ter deixado sua senha de acesso ao aparelho junto com o celular roubado.

Aplicável, portanto a excludente expressa no artigo 14, §3º, II do CDC, constatada que está a culpa exclusiva do consumidor.

Eis os fundamentos do pronunciamento.

3. CONCLUSÃO.

Sob o fundamento do art. 487, I, do Código de Processo Civil, dá-se a IMPROCEDÊNCIA do(s) pedido(s) do(a) demandante e, assim, dá-se a extinção do processo de conhecimento.

Ademais, dá-se a condenação do(a) demandante à obrigação de pagar as despesas do(s) ato(s) processual(is) e os honorários de advogado de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

4. Intime(m)-se.

São Bernardo do Campo, 9 de dezembro de 2022.